

1500152-05.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... pernoitando. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, bem como da confissão espontânea, com aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500152-05.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500152-05.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALVARO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ÁLVARO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 07, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 11h00, na Rua Santo Pereira da Rocha, nº 474, Centro, no município de Alfredo Marcondes, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, consistentes em: (i) 101 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total aproximado de 22,97g (vinte e dois gramas e

noventa e sete centigramas - lacre nº 0035759); (ii) 02 porções de cocaína, com peso líquido total aproximado de 0,43g (quarenta e três centigramas - lacre nº 0035760); (iii) 02 porções de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total aproximado de 133,19g (cento e trinta e três gramas e dezenove centigramas - lacre nº 0035758), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 16, fotografias de fls. 24/28 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 102/104. 2. Consta dos autos, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado possuía e mantinha sob guarda munições de uso permitido, especificamente 02 (dois) cartuchos de munição, íntegros, de calibre nominal 38 SPL, da marca CBC (lacre nº 0016685), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo pericial de fls. 105/107. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de drogas acima descritas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a trazer consigo algumas porções, bem como guardou e deixou em depósito o restante no interior da casa onde pernoitava, com vistas a comercializá-las ilicitamente. Ademais, o denunciado também possuía e mantinha sob a sua guarda as munições de uso permitido supramencionadas. Inicialmente, cumpre salientar que os policiais militares tinham prévios e recentes informes da exploração do tráfico de drogas pelo denunciado. No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado ÁLVARO e o adolescente Paulo Vitor Ferreira Pereira em frente à casa da Rua Santo Pereira da Rocha, nº 474, Centro, no município de Alfredo Marcondes, os quais, ao perceberem a equipe policial, empreenderam fuga para o interior do imóvel, razão pela qual decidiram abordá-los. Em revista, constataram que o denunciado ÁLVARO trazia consigo, em uma de suas mãos, 02 porções de cocaína, na forma de crack, e uma porção branca, em forma de "trouxinha", de cocaína, além de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais em dinheiro) em bolso de sua bermuda. No quarto onde o imputado pernoitava foram localizadas, no interior de uma bolsa sobre a cama, 99 porções de cocaína, na forma de crack, 01 "pino" de cocaína, 01 porção de maconha acondicionada em forma de "tijolo" e, em uma parede do quarto, outra porção de maconha em forma de "trouxinha". No mesmo cômodo também foram encontradas duas munições de revólver, calibre 38, da marca CBC (descrito no item 2). Nada de ilícito foi encontrado com o adolescente Paulo. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de dinheiro sem comprovação de origem lícita, afigura-se quadro seguro a apontar que as drogas apreendidas seriam destinadas ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 147/149), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 153), o despacho de fls. 154/158, de 12 de abril de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 216/217), pediu a total procedência da ação penal, com a condenação do réu por ambos os delitos imputados a ele na denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 221/237), pugnou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, CPP, quanto ao crime de porte ilegal de munições previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, alegando que não lhe pertenciam, mas já estavam na casa onde estava pernoitando. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, bem como da confissão espontânea, com aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15; pelo auto de constatação preliminar de fls. 16; pelo laudo químico toxicológico de fls. 102/104, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0035758) Descrição: Dois invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 142,93 grama(s) - Cento quarenta dois gramas noventa três centigramas. Massa Líquida: 133,19 grama(s) - Cento trinta três gramas dezenove centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0035759) Descrição: Cento um invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido petrificado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 29,95 grama(s) - Vinte nove gramas noventa cinco centigramas. Massa Líquida: 22,97 grama(s) - Vinte dois gramas noventa sete centigramas. Item 3 (Acondicionado sob o lacre 0035760) Descrição: Um microtubo(s) plástico(s) do tipo "Eppendorf" dotado(s) de tampa própria e um invólucro plástico fechado com calor encerrando porção de material sólido particulado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 6,57 grama(s) - Seis gramas cinquenta sete centigramas. Massa Líquida: 0,43 grama(s) - Quarenta três centigramas. Resultado dos itens 2 e 3: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 138/140; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha Paulo Vitor Ferreira Pereira, com 14 anos de idade, acompanhado de sua genitora, Sr^a. Marielza Pires Ferreira, declarou que a munições de arma não era do réu, não sabe de quem era, não era de ninguém. Afirma que o Alvaro é seu amigo de muitos anos. Ele estava em sua casa, mas não viu a prisão do réu, estava na sala enquanto ele estava no quarto deitado. Não sabe como ele foi preso, porque não escutou barulho de portão, de nada. colocaram a cara na porta e pediram para entrar, disse que não poderiam entrar, mas eles arrombaram a porta e entraram, perguntaram se tinha alguém dentro da casa, disse que não. Encontraram o "Alvinho" dentro do quarto, mas não viu comunicação entre os policiais e o Alvinho. Os policiais ficaram lhe perguntando várias coisas, se sabia de alguma coisa, disse que não. Começaram a bater no Alvinho então começou a gritar, falando que não, mas continuaram batendo nele. A Polícia não apresentou nenhuma droga na ocasião. Não viu a Polícia na casa do Alvaro, porque ele estava em sua casa, depois disso foram para a Delegacia. Na sua casa, não tinha visto se Alvaro estava com cocaína e maconha, lhe disseram apenas na Delegacia. Conhece o Alvaro Luiz no mínimo há dois ou três anos. Afirma que ele não usa droga, nem crack, maconha ou cocaína. Sabe que ele trabalhava. Afirma que Alvaro não usava maconha ou cocaína. Alvaro estava em sua casa no mínimo há duas ou três semanas, mas não morava com sua família. Ele passava um tempo juntos, saíam, brincavam e jogavam bola. Quando a polícia chegou não estava na frente da residência, estava deitado. Ele foi para sua casa apenas com as malas das roupas, mais nada que tinha visto. Ele guardava as coisas dele no seu quarto, na mala, ele tirava algumas roupas para lavar e depois as guardava em seu guarda-roupa. Não perguntou sobre a droga ou sobre a munição encontrada. Afirma que as munições não eram suas, que a Polícia imputou a posse para eles. Afirma que a munição não era do Álvaro, porque as munições, de repente, apareceram dentro de um sapato, como elas apareceram lá, se o sapato do seu sobrinho estava dentro de um saco, amarrado, para levar para a casa da sua irmã. Esse sapato era do seu sobrinho.

O PM José Maria Ribas, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em

patrulhamento pela referida via, juntamente com seu parceiro, PM Spirondi, quando se depararam com os dois indivíduos na via e ao avistarem a viatura, empreenderam fuga para dentro da residência, pulando o muro, e portava uma mochila nas costas. Houve necessidade de rapidamente efetuarem a abordagem e de imediato, localizaram na mão do indivíduo certa quantidade de pedras de crack e no interior da mochila, outras porções de crack e uma de maconha. Diante da situação, foi acionado o canil de Presidente Prudente para prestar apoio, onde localizou as munições pelo cão de fato. Não sabe onde foram localizadas as munições. O menor que morava na residência informou que o acusado pernoitava na sua casa. O Alvaro era usuário de drogas e já é de conhecimento da Polícia. No local é ponto de tráfico de drogas. O acusado não mencionou que usava droga. O menor, chamado Paulo Vitor mora na residência, mas não se recorda do nome dele. Eles estava sozinho em casa e os pais trabalhando. Naquela rua, na residência havia informações de era local de tráfico de entorpecentes. Não sabe se o adolescente é homossexual.

O PM José Norberto Spirondi, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pela Rua Santos Pereira da Rocha onde naquela residência já é conhecida como ponto de tráfico de drogas, e os indivíduos ao avistarem a viatura, pularam o muro da residência, um deles com a mão fechado e uma mochila nas costas. De imediato, tal situação foi motivo suficiente para realizar abordagem pois ali já é conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde foram abordados, entre a área e a porta da sala. Com esse indivíduo nada foi localizado de ilícito, e ao adentrar na residência, o outro indivíduo foi localizado no quarto da residência, que no momento da abordagem, tendo resistido, mas após contido, em sua mão estavam as duas pedras de crack. As porções de crack foram encontradas com o Alvaro, que já é conhecido nos meios policiais, que estava pernoitando naquela casa. Na mochila encontrada com Alvaro, havia pertences pessoais do Alvaro, que ele jogou na cama, reagiu a abordagem, sendo encontrada com ele as duas pedras de crack e um invólucro com substância branca, aparentando ser cocaína. Dentro da bolsa foi localizada 99 (noventa e nove) pedras de crack e um tijolo de maconha. Também foram localizadas munições no mesmo quarto que ele estava residindo, com o apoio do canil, as duas munições de arma de fogo de calibre 38, marca CBC.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

O réu Alvaro Luiz Pereira de Oliveira, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que estava dormindo e assim que acordou foi fazer uso de cocaína, e tinha também um pedaço de maconha. Tinha também alguns pinos de crack, mas não tinha munições, e não saiu correndo na calçada para dentro da casa. Estava dormindo e tinha acabado de acordar e fazia uso de drogas. Entraram na residência sem mandado e lhe agrediram. Afirma que mais usava que vendia, mas as vezes vendia droga também, estava desempregado, as condições estavam difíceis, trabalhava na colheita de batata e foi dispensado. Fez venda de maconha as vezes, mas não na casa onde foi encontrado, pois não mora lá, estava apenas de passagem, seu patrão mora naquela casa. Fazia a venda de drogas em Santo Expedito. O rapaz que o hospedou era seu colega. Fazia duas ou três semanas que estava lá na casa dele, namorava a irmã dele, é amigo da mãe dele. Já namorou com a irmã de João Vitor, não namora mais. O Paulo Vitor não faz tráfico de drogas, é de boa, não usa droga. Não sabe porque ele mentiu em Juízo no seu depoimento.

Encerrando-se a instrução processual.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (02 porções de

maconha pesando 133,19 gramas; 101 invólucros plástico contendo crack, pesando 22,97 gramas e 1 ependorf contendo cocaína, pesando 0,43 gramas), bem como numerário (R\$ 49,00), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, pois além de admitir ser usuário de drogas, também confirmou que vende drogas para subsistência, confirmado pelo relato dos Policiais Militares que já era de conhecimento o tráfico de drogas no local, e acabam por serem descobertos, o que ocorreu nos autos, além disso, é crível que ao avistarem a viatura, empreenderam fuga e foram abordados entrando na casa do menor João Vitor, que o auxiliava na mercancia de drogas, embora não há comprovação nos autos. Em revista pessoal, então, os Policiais localizaram com o réu duas pedras de crack e na mochila que portava, um tijolo de maconha e mais 99 pedras de crack, evidenciando sobremaneira a atividade espúria desenvolvida pelo réu naquela localidade.

Ademais, o desencontro das versões apresentadas pelo réu e pela testemunha João Vitor, que acabaram se confundindo entre eles, justamente porque não encontram justificativas para a atividade que vinham exercendo em sua residência.

Ademais, não se mostra verdadeira a narrativa que estavam dentro da residência, dormindo, o réu acordou e fez uso de drogas e a testemunha deitado, alegando ainda que os policiais "meteram o pé na porta", versão totalmente fantasiosa e risível, já que em momento algum trouxeram qualquer testemunha que pudessem confirmar a versão dada por eles, haja vista que estavam morando em casa de família, como disse o réu, namorou com a irmã de João Vitor e conhecia o pai e a mãe dele, bem como era a casa do seu patrão. Ao contrário, a Polícia encontrou a grande quantidade de droga, o dinheiro no imóvel usado como ponto de tráfico de drogas, portanto, suas versões são fantasiosas e desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos. Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do dinheiro que acabara de receber da venda do entorpecente, num total de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais), em notas diversificadas, sendo duas notas de R\$ 20,00, uma de R\$ 5,00 e duas de R\$ 2,00, típicas do recebimento de usuários na venda de drogas, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, um tijolo de maconha inteiro, que renderia muitas porções após ser fracionada para a venda, além das 101 (cento e uma) pedras de crack já embaladas para a venda e um pino de ependorf contendo uma porção de cocaína.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu no imóvel onde foi surpreendido.

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 24/28, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Ademais, o réu apresentou justificativas por estar na casa do menor João Vitor, e pela narrativa deste, verifica-se que mentiu em todas as circunstâncias que envolvem o réu com o tráfico de drogas, pois é certo que tinha conhecimento dessa condição. Inclusive disse não saber e nem viu as munições que foram encontradas em

sua residência.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que ambas as circunstâncias do encontro da droga com o réu, demonstram a principal destinação das drogas.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

No caso dos autos a polícia já tinha conhecimento por denúncias com informações que o local vinha sendo usado para realizar o tráfico de drogas e da forma como constatarem os policiais.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas naquela localidade, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor

previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 – Registro – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que os réus realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

2. Quanto ao crime de Porte Ilegal de Munições de Uso Permitido, prevista no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

A materialidade do delito narrado na denúncia e imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, principalmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo pericial de fls. 105/107; bem como pela prova oral carreada para os autos.

Em que pese a prova incontestada da materialidade delitiva, não se fez possível dirimir, com a necessária certeza, a identificação da autoria.

O menor João Vitor relatou que não sabia das munições e que elas não pertenciam ao réu Alvaro, pois foram encontradas dentro de um sapato do seu sobrinho, que estava dentro de um saco, e que seria devolvido ao seu sobrinho e em solo policial nada foi mencionado acerca da localização das munições.

Os PMs José Maria Ribas, foi acionado o canil de Presidente Prudente para prestar apoio, onde localizou as munições pelo cão de faro. Não sabe onde foram localizadas as munições, e José Norberto Spirondi, disse que foram localizadas munições no mesmo quarto que ele estava residindo, com o apoio do canil.

Por sua vez, o réu Alvaro de Oliveira, confessou que tinha também alguns pinos de crack, maconha e cocaína, mas não tinha munições.

Os depoimentos prestados foram divergentes, não se podendo conhecer o verdadeiro possuidor das munições, pois a palavra dos policiais foi superficial, tendo um deles dito que não sabe onde foi as munições foram localizadas, e o outro apenas que foram localizadas munições, em que pese terem sido localizadas no quarto onde dormia, ele não morava naquela residência, mas segundo o menor, estavam dentro do sapato do sobrinho, dentro de um saco, e sua versão não foi contradita por nenhuma outra da prova produzida em Juízo.

Portanto, nenhuma outra prova se produziu sobre o crivo do contraditório que pudesse sustentar a acusação acerca do crime de porte ilegal de munição de uso permitido. Estando os autos eivados de dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação.

Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito.

Com efeito: "Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova" (Voto Nº 4.246). Daí porque, "uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de

segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório.”(Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Ressalte-se, por oportuno, que o ônus de provar a materialidade e a autoria do crime compete à acusação, não se podendo presumir a culpabilidade do réu, mas sim a sua inocência, como decorrência lógica do princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci: “princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense: 2014).

Como já se disse, ainda que com boa vontade e trabalho árduo por parte dos agentes da Lei, nem sempre será possível reunir elementos seguros para embasar condenações criminais. E isso faz parte da missão do aparato de repressão criminal do Estado. Nesse ponto, cumpre ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros seguros para que as condenações criminais estejam sempre embasadas em provas suficientes e hábeis a formar um convencimento indene de dúvidas, o que não ocorreu nos presentes autos. Desse modo, o réu deve ser absolvido, por ausência absoluta de qualquer elemento que embase a autoria que lhe é imputada quanto ao crime de ameaça.

O princípio do “in dubio pro reo” não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Nesse sentido é a jurisprudência, verbis:

Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime. (RJTJERGS 177/136, apud Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição, Atlas, 1997).

A solução, portanto, é a improcedência total da ação da ação penal.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

“Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem.

Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENHIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.[...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o

entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114). Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

"[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES

CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]". (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário embora registre antecedentes, não servem para indicar maus antecedentes ou reincidência, já que não há processos com condenação, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, que ainda lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea do réu em Juízo, conforme preceitua o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidos em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e

prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062